DOI: 10.13796/j.cnki.1001-5019.2018.04.017

# 农用地开发许可权市场化改革路径之选择

张先贵

摘　要:长期以来,受传统计划经济体制和路径依赖惯性的影响,在农用地开发许可权制度目标的实现方式上,无论是实定法还是实践,主要践行的都是单一的"命令—服从"式的公法模式,掩蔽和淡化了地方政府、农地权利人、集体经济组织等多元化主体的利益诉求。实践中,包括地方政府在内的诸多主体,绕开和规避农用地开发许可权的违法违规用地行为频繁而又普遍,从而在一定意义上宣示了这一权力的运行步入了失灵的困境。为此,立足于当下的客观实际,面向市场化的价值取向来改革我国现行农用地开发许可权,以积极回应多元化主体的利益诉求,从而突破这一权力运行之困境,已成学理之共识。基于当下诸多土地改革试点方案之观察,可以得出:我国农用地开发许可权市场化改革,在具体的路径层面,存在初级形态下的"土地换保障"模式、中级形态下的建设用地"增减挂钩"模式和高级形态下的"地票"交易模式。这三种模式利弊共存,但立足于现有制度资源的约束条件、遵循三种模式内在的变迁规律、对不同模式社会效果之比较以及综合考量其成本和效益等因素,"地票"交易模式应是实现我国农用地开发许可权市场化改革目标的最优化路径,或者说是"最不坏"的选择。现行法应借由相应的法技术对其做出积极的回应,以实现其在实定法上的"落地生根"目标。

关键词:农用地开发许可权;市场化;土地换保障;增减挂钩;地票

中图分类号:D922.3　　文献标识码:A　　文章编号:1001-5019(2018)04-0141-09

基金项目:2017 年度国家社会科学基金青年项目"'准征收'与行政补偿法律制度研究"(17CFX012)

作者简介:张先贵,华东政法大学法学博士后流动站研究人员(上海　201620),上海海事大学法学院副教授、硕士生导师(上海　201306)。

就实定法层面而言,我国的土地管理权是由一系列权力组成的权力束结构体系①。在这一权力束结构体系中,农用地开发许可权是其重要的组成部分,其存在的价值和功能主要是严格限制或控制农用地转为建设用地的数量、规模和时速,以协调好耕地资源的保护与建设用地之供给二者之间的关系,从而力争实现"双保"(即"保红线"和"保增长")的目标。在我国现行土地管理权面向市场化价值取向改革的当下,农用地开发许可权亦不例外。具言之,长期以来,由于受传统计划经济体制和路径依赖惯性之影响,在农用地开发许可权法律制度目标的实现方式上,无论是实定法还是实践,主要践行的都是单一的"命令—服从"式的公法模式。就其本质而言,这一模式掩蔽和淡化了地方政府(主要是县、市级人民政府)、农地权利人、集体经济组织等多元化主体的利益诉求。实践中,包括地方政府在内的诸多主体,实施绕开和规避农用地开发许可权的违法违规用地行为频繁而又普遍,从而在一定意义上宣示了这一权力的运行步入了失灵困境。为此,立足于当下的客观实际,面向市场化的价值取向来改革我国现行农用地开发许可权,以积极回应多元化主体的利益诉求,从而突破这一权力运行之困境,迫切而又必要。

故而,近年来,本着化堵为疏的理念,从积

① 张先贵《权力束视角下我国土地管理行为法权表达及意义——立足于〈土地管理法〉修改背景下的审思》,《社会科学辑刊》2016 年第 5 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

极回应多元化主体的利益诉求出发,围绕着农用地开发许可权市场化改革的诸多试点方案或模式相继出现,譬如,“土地换保障”模式、建设用地“增减挂钩”模式、“地票交易”模式,等等。客观而言,尽管这些不同的试点模式或方案因其自身存在程度不同的缺陷和弊病而在实践中引发了许多争议和纠纷,但不可否认的是,这些不同的模式或方案都是对我国现行农用地开发许可权市场化改革的最为直接的宣示,或者说构成了我国当下农用地开发许可权市场化改革路径的演进历程。

当然,由此而带来的问题是:法理上,上述三种不同试点方案的利弊何在?我国当下农用地开发许可权市场化改革路径究竟选择何种模式或方案更为稳妥?一旦选择某种具体方案后,现行的实定法层面该如何应对?鉴于此,本文主要以我国农用地开发许可权市场化改革路径之选择为研判对象,拟对上述问题作深入的法理求解。实际上,在我国土地制度改革践行“实验主义”进路的当下,从法理层面,认真对待这些不同试点方案或模式,吸取其教训、积累其经验,具有非常重要的理论价值和实践意义。

## 一、初级形态:“土地换保障”模式

就“土地换保障”模式而言,其在实践中主要是以农民自愿放弃宅基地使用权和承包地使用权,然后获取市民的身份和相关社会保障的权益为基本特征。尽管各地在实践中针对这一模式实行了诸多具体的不同形式,但基于其具体内容上的大同小异,总体上可将其概括为“承包地换社保”“宅基地换住房”模式;具体而言可分为以下四种模式:

一是 2005 年天津的“宅基地换房”模式。在这一模式中,华明镇作为天津“宅基地换房”审批试点镇,该镇的农民可以用自己的宅基地,按照规定的置换标准换取小城镇内一套住房,迁入小城镇居住①。

二是 2008 年浙江嘉兴推出的“两分两换”模式。在这一模式中,宅基地与承包地分开,搬迁与土地流转分开。以承包地换股、换租、换保障,推进集约经营,转换生产方式;以宅基地换钱、换房、换地方,推进集中居住,转换生活方式②,按照“土地节约集约有增量,农民安居乐业有保障”的要求,以达到“农业生产经营集约、农村人口要素集聚,提高农民生活水平和生活质量”的目的③。内容上,这一模式乃是农民以宅基地置换城镇房产、以土地承包经营权置换社会保障的本质体现④。

三是 2006 年成都市温江区实施的“双放弃、三保障”模式。所谓“双放弃”,是指农民自愿放弃土地承包经营权和宅基地使用权的,在城区集中安排居住,并享受与城镇职工同等的社保待遇。而“三保障”是指农民变成市民需要的三个保障条件:一是能够在城市的二、三产业就业;二是在城市拥有自己的住宅,家属能够在城市居住;三是能够享受城市居民享受的社会公共服务⑤。

四是 2010 年重庆市户籍改革中的“宅基地换住房、承包地换社保”模式。就这一模式而言,当地政府曾形象地将这一改革措施称为转户农民自愿“脱掉三件衣服,穿上五件衣服”。所谓“脱掉三件衣服”是指转户农民放弃农村土地承包经营权、宅基地使用权和林地使用权,而“穿上五件衣服”是指穿上包括城市就业、社保、住房、教育、医疗在内的五件衣服。

客观而言,在“土地换保障”模式下,农民将其闲置的宅基地使用权置换城镇房地产,将其分散的土地承包经营权置换城市市民享有的社保,至少有以下几个方面功能:一方面为地方政府在新增加建设用地指标持有不足的情形下的农转非提供了新的路向,体现了化堵为疏的创新理念;同时,这亦有助于解决当下我国农村宅基地使用权大量闲置而导致的资源得不到有效利用的困境。另一方面这有助于将分散的土地承包经营权集中起来,进行规模化经营,对推动农地资源的有效利用,实现这一财产价值的最大化,推动农村集体经济的有效实现具有重要意义。不过,从实践来看,这一模式的缺陷亦

① 刘润秋《土地流转占补平衡:典型模式与制度缺陷》,《社会科学研究》2011 年第 4 期。
② 周林洁《两分两换:嘉兴快速稳健推进新型城市化的理性选择》,《城市发展研究》2011 年第 3 期。
③ 王彧、郭锦辉、张海生《“两分两换”:嘉兴探索优化土地资源》,《中国经济时报》2009 年 10 月 15 日第 4 版。
④ 仇恒喜、汪雷《“两分两换”助推农村土地变迁:基于嘉兴经验的理论分析》,《经济社会体制比较》2010 年第 6 期。
⑤ 孙建伟《建设用地置换视域下土地发展权的法理基础与制度构造》,《暨南学报》2017 年第 12 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是非常明显的:

其一,合法性受质疑。从“土地换保障”模式的内容来看,其主要包括“承包地换社保、宅基地换住房”两大方面,显然,“承包地换社保”明显违法了我国现行《土地管理法》第 4 条、第 44 条之规定,即在现行法上,对于将农用地转为非农用地,从事农地非农化开发建设,必须依法办理农用地转用审批手续。国家设置这一程序就是为了保护 18 亿亩耕地红线,进而实现国家粮食安全的重大目标。因此,如果允许地方政府与承包地使用权人之间进行互换,并允许地方政府取得土地承包经营权后进行农地非农化开发建设的话,这显然是对现行土地用途管制的规避和绕开,有违我国现行耕地资源保护的诸多制度性安排,因而其合法性面临正当性危机。

其二,置换范围偏狭、受限较多以及远郊农村难以分享城市化带来的利益。从实践来看,对于“宅基地换住房”模式而言,尽管其具有诸多的功能和价值,譬如,对于政府来讲,这一模式为其提供了规划外新增建设用地,从而解决了新增建设用地供需之间的矛盾; 对于农民来讲,在这一模式下,经过置换后,农民的财产性收入会得到明显提高,但是,“宅基地换住房”模式存在的最大缺陷是,城乡建设用地置换的范围非常狭窄,仅仅是对城市周边农村集体土地上的宅基地进行置换,被置换出来的建设用地指标与具体地块相捆绑。客观而言,这一做法虽然有助于控制交易范围,被复垦的耕地在数量和质量上能够得到一定程度上的保障,而且国家监管的成本亦较低,但是对于广大偏远的农村( 即远郊农村) 而言,在这一模式下,由于其远离城市,虽然存在大量闲置的集体建设用地,但不能用于城市建设用地指标,因而其难以分享城市化带来的利益。这显然会造成不同地区农村之间发展上的不平衡。

其三,违背自愿原则,农民权益没有得到很好的保障。在“土地换保障”模式下,无论是“宅基地换住房”,还是“承包地换社保”,均应遵循自愿原则,即只有获得农民的同意,方可实施这一政策。然而,从实践来看,地方政府为了获得规划外的新增建设用地,往往在行政权的主导下集中统一推进这一政策试点,少数农民的不自愿被集体多数决原则所绑架,出现了所谓的“农民被上楼”等事件,损害了部分农民的合法土地权益,严重影响了社会的稳定①。另外,对于农村土地承包经营权的流转亦是一样,必须遵循自愿的原则。但在“承包地换社保”模式下,变相地强迫农民流转土地的现象时常发生。这些违背农民自愿原则的行为,最终使得试点政策实施的效果大打折扣。

其四,没有充分利用市场机制来配置资源,名为交易,实为行政决定,是计划配置资源的实质体现,难以实现农民权益保护的最大化目标。从形式上讲,无论是“宅基地换住房”,还是“承包地换社保”,都应遵循市场规律,充分利用市场机制来实现资源的优化配置,但从实践来看,农民腾退出来的宅基地能够置换政府提供的多大面积的住房几乎都是由行政机关来决定的,并没有体现市场交易的属性。实际上,尽管城市房地产的价格要高于农民住房财产权的价值,但是城市建设用地使用权是有期限限制的,而农民的宅基地使用权带有福利属性,是国家无偿分配的,具有时间上的永久性或无期限限制等特征。因而,从长远来看,农民将其无期限限制的宅基地使用权置换有期限限制的建设用地使用权,未必能够实现农民权益的最大化。

由此可见,作为我国现行农用地开发许可权市场化改革雏形的“两分两换”模式,因主要践行的是行政权主导下的“命令—服从”模式,而使其具有市场化交易之形而无之实。另外,这一模式的设计更主要是为地方政府寻求规划外建设用地指标提供思路,体现了积极回应地方政府独立利益诉求的鲜明特征,而忽视了对农民、集体经济组织等其他主体之利益诉求的有效回应和保护。是故,这一模式的内在结构亟须调整和升级。

至此,法理上,将“两分两换”模式定位为我国农用地开发许可权市场化改革路径的初级形态,较为妥当。

## 二、中级形态:建设用地“增减挂钩”模式

鉴于“土地换保障”模式仅是我国农用地

① 参见周仁标《论社会稳定与地方治理》,《安徽师范大学学报( 人文社会科学版) 》2017 年第 5 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

开发许可权市场化改革路径的初级形态,以及这一模式存在上述诸多的缺陷,克服这些弊病,升级其形态,尤为必要。在这一背景下,建设用地“增减挂钩”模式(又称为“指标挂钩”模式)应运而生。根据国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138 号)的规定,所谓城乡建设用地“增减挂钩”是指依据土地利用总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区(以下简称项目区),通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现增加耕地有效面积,提高耕地质量,节约集约利用建设用地,城乡用地布局更合理的目标①。城乡建设用地增减挂钩制度以项目区为单位组织实施工作,通过试点规划下达周转指标进行调控管理,在规定时间内用拆旧地块整理复垦的耕地面积归还周转指标②。2004 年成都市成为“增减挂钩”模式的最早政策试点,之后国务院和国土资源部相继颁布一系列文件对这一模式进行规范。为防止“增减挂钩”项目带来的风险,国土资源部于 2006 年发布了《关于天津等五省市城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩等第一批试点的批复》(国土资函〔2006〕269 号),明确批准天津、江苏、山东、湖北、四川五省市作为城乡建设用地增减挂钩首批试点地区,并且明确要求“增减挂钩”项目须经国土资源部审批,“增减挂钩”指标只能在项目区内流转。2009 年又批准了 19 个省区加入城乡建设用地“增减挂钩”试点地区。

相对于“土地换保障”模式,“增减挂钩”模式具有以下几方面优点:

其一,城乡建设用地“增减挂钩”项目的实施半径扩大,实施范围扩大到包括远郊农村在内区域。显然,这改变了“土地换保障”模式下被置换出来的建设用地指标与具体地块相捆绑的特征,从而意味着被置换出来的建设用地指标开始突破了具体地块的限制③。另外,“增减挂钩”项目实施范围的扩大,使得区域之间的比较优势更加凸显④。

其二,将远郊农村闲置的宅基地、集体建设用地整理后置换出来的建设用地指标,在“增减挂钩”项目范围内可以独立交易,即用于城市近郊农用地转用指标或新增建设用地指标。这一方面可以在不增加建设用地总量指标、不减少耕地保有量指标的情形下,解决城市新增建设用地指标供需之间的矛盾,实现耕地资源的有效保护与经济不断发展的双重目标,即达到“双保”(保红线、保增长)的要求;另一方面,这一做法对于克服广大边远地区农村不利的区位因素,使其在城市化过程中亦能够分享相应的城市化收益具有十分重要的意义。此外,这一做法对于实现城乡建设用地之空间上的优化布局,提高土地资源利用效率亦起到了非常重要的推动作用。

其三,相对于“土地换保障”模式而言,“增减挂钩”模式的最大优点在于,没有违反现行的法律法规的规定。相反,这一模式是在现行体制内对当下我国土地管理模式的一种创新⑤。尽管这一模式在实践中出现不同程度的偏差和异化,但在笔者看来,这一模式具有相当的合理性、正当性和科学性,尤其是在当下我国社会转型时期,对创新我国土地管理模式意义重大。

当然,任何事物都是利弊共存,城乡建设用地“增减挂钩”模式虽然具有上述诸多优点,但亦同样具有诸多不足之处:

其一,在“增减挂钩”项目实施中,“挂钩”项目的实施半径被严格限制在具体实施的地方的项目区内进行,其指标的运行是按照“总量控制、封闭运行”的原则来交易。这意味着将农村闲置的宅基地和集体建设用地复垦所腾退出来的建设用地指标只能在项目区范围内进行小范围的置换,而不能突破项目区范围进行置换。而有关项目区的选定需要获得国土资源部

① 国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138 号)第 2 条的规定。

② 国土资源部《关于规范城镇建设用地增减挂钩与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》(国土资发〔2005〕207 号)。

③ 李海梅《城乡建设用地增减挂钩政策实施的异化风险及预防》,《中州学刊》2013 年第 1 期。

④ 苟兴朝《城乡建设用地增减挂钩中农民合法权益保障研究——基于马克思级差地租理论视角》,《农村经济》2012 年第 4 期。

⑤ 程世勇《中国农村土地制度变迁:多元利益博弈与制度均衡》,《社会科学辑刊》2016 年第 2 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的审批,由国土资源部来决定项目区的位置和范围,并进而决定“增减挂钩”指标交易的范围和半径。因此,可以说,“增减挂钩”项目实施权完全由政府决定,“增减挂钩”项目中指标的交易半径和范围仍然受诸多的限制。

其二,在“增减挂钩”项目实施中,由于建设用地指标是在事先选定的项目区范围内进行的封闭式交易,对于建设用地指标的供给主体和需求主体而言,双方都是确定的,没有其他交易主体可供双方选择,这意味着封闭的指标交易市场缺乏竞争性,类似于双边垄断的市场结构①。此外,在这一模式下,指标定价等诸多事项完全是由政府决定的,而不是利用市场机制来发现指标的价格。因此,总体上而言,“增减挂钩”指标被严格限制在项目区内进行交易明显缺乏效率,市场机制难以得到充分的发挥。

其三,在“增减挂钩”项目实施中,由于项目实施的位置和范围完全是由政府决定的,这必然会带来这样的结果,即被选入项目区的远郊农村,通过对集体建设用地的整理获得的建设用地指标,在流转到建新区后,可以获得高额的补偿款; 而那些没有被纳入项目区的远郊农村,则无法通过整理闲置的宅基地和集体建设用地进行指标流转来获得收益。因此,这不利于实现与项目区相似情形和条件的其他远郊农村集体经济组织的发展,相反,这一模式的实施会带来一定程度上的不公平性。

其四,在“增减挂钩”项目实施中,实行的是先占地再补地原则(即“先占后补”原则),即先占用耕地建设,再在项目区范围内进行补偿耕地,这在实践中经常会出现“占有余”而“补不足”的弊端。显然,这对保护有限的耕地资源极为不利。

由此可见,相对于“土地换保障”模式而言,作为我国农用地开发许可权市场化改革路径的“增减挂钩”模式,在具体的实施方式上明显有所升级。换言之,尽管现行的“增减挂钩”模式受到较多的行政权主导,仍然需要对其内在的结构进行升级或革新,以提升其市场化的程度,但不可否认的是,相对于“土地换保障”模式而言,这一模式在指标市场化交易的范围和力度上明显有所突破。因此,将“增减挂钩”模式定位为我国农用地开发许可权市场化改革路径的中级形态,较为妥当。

## 三、高级形态: “地票”交易模式

正是由于“增减挂钩”项目在实施的过程中存在上述诸多的不足,影响了公平和效率价值的有效实现,为突破这一困境,以重庆为代表的“地票”交易模式由此而产生。“地票”交易又称为指标交易,是与实物交易相对的概念②。对于“地票”交易而言,其交易的对象乃是“指标”,这里的指标乃是建设用地(挂钩)指标。所谓建设用地挂钩指标是指将农村闲置的宅基地及其附属设施用地、集体建设用地(乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业用地等)复垦为耕地后,可用于建设用地的指标。因此,“地票”交易实质上就是建设用地指标的交易。就其基本原理而言,其“是将农村闲置的宅基地、集体建设用地等整理、复垦成耕地,经相关行政主管部门验收合格后产生相应的用地指标(即新增建设用地指标或建设用地挂钩指标或地票),然后由土地行政主管部门向土地使用权人发给相应面积的‘地票’凭证,并在农村土地交易所公开交易,需要建设用地的人可以通过公开竞购的方式取得该用地指标后,可以申请将其纳入年度新增建设用地计划,增加等量城镇建设用地”③。换言之,地票交易也就是“获得对土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围的农村进行等量新增建设用地征购的权利”④,并在指标落地时(即该买家通过公开的市场招、拍、挂程序后,最终竞拍成功)支付地票费冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。

相对于上文所谈的“增减挂钩”项目模式而言,“地票”交易模式乃是对“增减挂钩”项目

① 张海鹏《我国城乡建设用地增减挂钩的实践探索与理论阐释》,《经济学家》2011 年第 6 期。

② 根据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的规定,农村土地交易所交易品种包括两种: 一是实物交易,称之为实盘,包括农村集体土地使用权、农村承包经营权流转和林权交易等; 二是指标交易,即地票交易,称之为虚盘。

③ 王彦美、谷达华、牛德利、汪鹏《重庆市地票交易中置换耕地折算方法研究》,《国土资源科技管理》2010 年第 5 期。

④ 梅哲、陈霄《城乡统筹背景下农村土地制度创新——对重庆土地制度改革的调查研究》,《华中师范大学(人文社会科学版)》2011 年第 3 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

模式的进一步贯彻和创新,而非变革。不过,二者都是为城乡建设用地增减平衡的目标服务的。换言之,"地票"交易模式优化了城乡建设用地增减平衡目标的实现方式,是对"增减挂钩"项目模式所存在的缺陷进行改进和优化的重大创新和完善。因此,相对于"增减挂钩"项目模式而言,"地票"交易模式具有如下几方面优点:

其一,"地票"交易实现了指标的市场交易,有助于政策效率价值的提升。在建设用地"增减挂钩"项目模式的实施中,"挂钩"指标的交易双方都是确定的,没有第三方交易主体可供选择,而且指标的交易价格也是完全由政府决定的。而"地票"交易模式在允许"增减挂钩"的范围内适用市场竞争的方式,即由指标的供给方(拆旧区)和需求方(建新区)自由选择各自的交易对象。显然,这一做法标志着指标交易从计划管制走向了市场化竞争,指标的价格亦不再由政府完全定价,而是在市场的竞争中被发现。

其二,当赋予指标的供给方(拆旧区)和需求方(建新区)自由选择各自的交易对象时,就意味着指标交易对象的逐渐增加,即指标供给主体和需求主体的多元化。显然,这一方面扩大了"增减挂钩"的范围,使农村闲置的宅基地和集体建设用地能够大范围、远距离的置换。从重庆的"地票"交易结果来看,远郊农村的建设用地指标可以卖到主城区,用于主城的建设用地,而且价格较高。这不仅能够提升远郊农村的土地价值,而且亦有助于城乡建设用地的优化布局。另一方面指标交易主体的增加亦使得指标交易的组织形式发生了重大变化,即由之前的一对一谈判模式转变为交易所内的多方参与模式。此时在交易所内交易的挂钩指标就属于我们所说的地票。

其三,"地票"交易模式采取的是"先造地后用地"的模式,即先把农村闲置的宅基地、集体建设用地复垦为耕地后,才能在城市增加等量的建设用地。这一做法显然改变了"增减挂钩"项目模式下的"先占后补"原则,有助于更好地保护稀缺的耕地资源。

鉴于"地票"交易所具有的上述诸多功能和特点,学界给予了较多的好评。譬如,有学者指出:"在目前我国经济高速发展对土地形成特别依赖和粮食安全、耕地保护红线不能突破的双重压力下,如何走出一条既能有效保护耕地,保住耕地红线,又能不影响而且能够支持经济快速发展,是摆在我们面前一道难以破解的国家难题。重庆首创的'地票'交易,无疑是为这道国家难题的破解寻求出了一个新的方向。"①亦有学者指出,之所以设计指标或者地票这个形态,无外乎有两个原因:一是"随着城市化、工业化的快速发展,城镇建设出现了极度膨胀,城镇建设用地的紧张和农村宅基地闲置的城乡二元土地结构矛盾越来越突出,直接影响我国城乡统筹发展的步伐"②;二是零星散布在广大农村的土地特别是宅基地、集体建设用地要实现有效流转是很困难的,只有把"农民自愿申请的,经过整理整治的,按照统一标准验收合格的"土地用途属性转化为指标形态,才能真正推动它实现远距离、大范围的流转③。亦唯有如此,这些在区位上不占优势的土地资源价值才能得以有效实现,其权利人方可分享城市化背景下的巨大土地收益。此外,还有学者从证券化层面指出:"地票交易制度的价值在于通过证券化形式创新土地交易方式,发挥了统筹配置城乡建设用地资源的作用,创造性地运用了证券化的融资功能、资源优化配置功能、财富收入分配功能以及公共政策促进功能,为农村集体建设用地资本化,以及建设城乡统一建设用地使用权市场化探索了新途径。"④

实际上,在我国城乡社会二元结构已被逐渐打破、城市就业市场已经全面向农村劳动力开放、土地对农民生存保障功能越来越弱化、农民生存依赖的多元格局已经基本形成、户籍制度改革正在紧锣密鼓推进的社会背景下,挖掘农村闲置的宅基地和集体建设用地,将其复垦为耕地,置换成城市发展所需要的建设用地指

① 刘俊、杨惠、白庆兰等《地票的制度基础与法律性质》,北京:法律出版社,2012 年,第 19 页。

② 马智利、李军、段大玲《基于地票制度下的成渝宅基地流转模式对比分析》,《兰州商学院学报》2012 年第 4 期。

③ 梅哲、陈霄《城乡统筹背景下农村土地制度创新——对重庆土地制度改革的调查研究》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2011 年第 3 期。

④ 岳彩申、张晓东《证券化视角的地票交易制度创新及立法路径》,《重庆社会科学》2011 年第 9 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

标,即“地票”交易,不仅必要而且可行。可以说,这样的改革创新,完全实现了在不减少耕地资源的前提下,保证城市经济的快速发展的“双保”目标,符合国家节约、有效利用土地资源的指导思想和原则①。另外,必须指出的是,我国对新增建设用地实行指标管理的目的在于防止耕地“农转非”的失控,从而影响国家的粮食安全目标之实现。但从实践来看,国家每计划年度内下达的新增建设用地指标往往难以满足地方经济发展的需要,通过复垦所产生的指标便成为补充建设用地的重要来源。因此,在城市化、工业化快速发展的社会背景下,如何协调好经济建设与耕地资源保护的关系是一个亟待解决的难题,“地票”交易制度无疑是一个积极的探索。重庆的“地票”制度在有效地保护稀缺的耕地资源,确保耕地的占补平衡,盘活农村闲置的宅基地、集体建设用地,实现农村土地资源的节约集约利用,推动偏远地区农村经济的发展以及解决城镇建设用地短缺方面起到了重要作用。是故,有学者认为,在重庆和成渝经济区统一的“地票”交易市场稳定运行一段时间后,应积累其经验,逐步建立全国性的统一“地票”交易市场,以此实现全国范围内城乡建设用地的合理配置,这将有力地推动我国城市对农村的反哺、工业对农业的带动,从而真正地实现统筹城乡的协调发展目标②。

当然,亦有学者指出重庆“地票”交易制度在运行中出现了一些社会问题,譬如,出现了功利主义需求与制度理性相冲突、政府机构职能异化、农民权益保障不足、政策调控高而市场机制弱化等现象,而这些因素制约着地票制度的良性发展。针对上述问题,这学者进一步指出,地票制度的改良应当实现权益保障机制的修正与完善,充分发挥政府的管理和服务职能,建立健全农民利益表达、分配和保障机制,进一步完善地票交易的制度设计、运作模式和监管体系③。

在笔者看来,尽管“地票”交易在实践中暴露出了一些问题,亟须进行完善,但并不能由此而否认这一方案的必要性与可行性。从本质层面而言,如果说“土地换保障”模式、建设用地“增减挂钩”模式分别属于指标交易市场之初级形态和中级形态的话,那么重庆的“地票”交易模式则属于指标交易市场的高级形态。

综上述及,围绕着农用地开发许可权市场化改革的路径探索,先后经历了“土地换保障”模式、城乡建设用地“增减挂钩”模式和重庆“地票”交易模式三种形态。就其实质而言,三大模式的内容均是围绕着指标交易这一核心议题而展开的。以历时维度观之,三大模式的演变体现了指标交易从初级形态到中级形态再到高级形态的发展历程,标志着我国农用地开发许可权市场化改革路径的不断优化、升级和更新。相比较而言,现行的“地票”交易模式乃是目前农用地开发许可权市场化改革的最佳路径选择。从某种意义上讲,这一模式代表着我国现行农用地开发许可权市场化改革路径的未来路向。就其缘由而言,这是由现有的制度资源约束条件、三种模式的内在变迁之规律、社会效果之比较以及制度运行成本和效益之权衡等多种因素所决定的。具体而言:

其一,从现有的制度资源约束条件来看,“地票交易”模式为最佳的路径选择。实践中,地方政府能否将具体地块的农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设,主要取决于其是否持有新增建设用地指标。借由指标这一数字化形式来对地方政府农转非进行严格控制,构成了我国土地管理的重要特征。现行法上的土地用途管制、土地开发许可等制度均是践行指标管制模式的制度表达。

鉴于这一制度构造样态和路径依赖的惯性,当下的“地票交易”模式乃是在继续践行新增建设用地指标行政配置模式的基础上,在一定的条件下,借由市场机制,实行用地指标的市场化交易,从而解决指标行政配置模式的不足,以此回应多元化主体的利益诉求。换言之,“地票交易”模式并不是对传统指标行政配置模式的彻底否认,而是在对传统指标计划配置机制之完善的基础上所做出的一种尝试,或者说一种创新。因此,相对而言,实施“地票交易”模式,并不是对现行的制度体系的彻底变

① 刘俊、杨惠、白庆兰等《地票的制度基础与法律性质》,第 19 页。

② 谢来位《成渝地票交易制度及其价格形成机制比较》,《价格理论与实践》2011 年第 8 期。

③ 杨飞《反思与改良: 地票制度疑与探——以重庆地票制度运行实践为例》,《中州学刊》2012 年第 11 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

革,而恰恰是在受现有制度资源约束条件下的一种创新。

其二,从三种模式社会效果之比较来看,“地票交易”模式为最佳的路径选择。上文已对“土地换保障”模式、建设用地“增减挂钩”模式以及“地票交易”模式的各自利弊进行了诠释,不难看出,行政权主导最为鲜明的“土地换保障”模式,有市场化交易之形而无其实,农民“被上楼”事件的频发宣示这一模式亟须革新或调整。建设用地“增减挂钩”模式,虽扩大了市场化交易色彩,降低了行政权主导的程度,但因其始终是在项目区内进行封闭式交易,并且在指标交易的价格上实行的是政府定价,最终使得这一模式效果不佳,难以真正发挥市场在土地资源配置中的基础性作用,进一步制约了土地指标交易市场的扩大化。而“地票”交易,则体现了鲜明的市场化交易色彩,其不仅有地票交易所等市场化的交易机构,而且交易的对象面向不特定的市场主体,此外指标交易的价格等诸多事项亦非借由行政方式事先来确定①。因此,可以说,“地票”交易的市场化程度最高,其社会效果亦是最佳的。目前,有许多地方都在推广这一模式②。

其三,从三种模式内在变迁之规律来看,“地票”模式为最佳的路径选择。从上文的分析来看,“地票交易”模式的产生,乃是在“土地换保障”模式、建设用地“增减挂钩”模式的基础上不断完善和升级的结果。因“土地换保障”模式面临行政权主导和合法性危机的质疑,而被建设用地“增减挂钩”模式所取代。虽然“增减挂钩”模式体现了指标交易的市场化色彩,但在项目区的选择、指标交易的对象以及价格等事项上仍是由行政权主导和决定,制约了土地指标交易市场化的规模和范围,因而其效果并没有得到很好的发挥。为克服“增减挂钩”模式的弊端,“地票”交易模式应运而生。并且,这一模式主要致力于充分发挥市场机制来解决指标交易这一难题。由此可见,从“土地换保障”模式到建设用地“增减挂钩”模式再到“地票交易”模式的演进历程,不仅宣示了我国农用地开发许可权市场化改革路径渐趋理性化和成熟化,而且亦充分体现出制度步入理性轨道的内在变迁脉络。

其四,从制度运行成本和效益来看,“地票交易”模式为最佳的路径选择。从法理上讲,任何路径的选择都需要考量其成本与效益,农用地开发许可权市场化改革路径之选择亦不例外。只有以最小的成本,获得最大的效益,方可使得所选择的路径符合比例原则,进而实现社会各方主体利益之平衡的目标。前文已述,当下试点政策所践行的“地票交易”模式,是在践行现有的制度资源约束基础上所做的创新,其不仅能够克服传统新增建设用地指标行政配置模式所存在的诸多缺陷,而且亦因其不动摇现有的制度规范体系,而使得这一模式或方案的运行具有成本低、风险小、各方主体可接受性较高等诸多优点。

此外,这一模式践行化堵为疏的理念,充分利用市场机制,不仅积极回应地方政府独立的利益诉求,为地方政府寻找规划外建设用地指标创造了一种思路,而且亦顺应社会情势变迁之需要,对农民、集体经济组织等各方主体的利益诉求做出了积极回应。可以说,从制度设计的弹性化角度来讲,将不同主体的利益诉求嵌入规范结构体系中,是“地票”交易模式最为创新的亮点。这不仅降低了制度过于刚性而使其难以激励不同主体自觉遵守的弊端,而且亦实现了社会转型时期制度革新成本最低、收益最大的目标。

当然,最后需要指出的是,尽管这一模式还存在诸多不完善的方面,但在大的方向层面并没有问题,我们只需要针对这一模式存在的缺陷和不足进行体制内的改进和完善即可。就此而言,在笔者看来,现阶段,针对“地票交易”这一新生事物,在法律适用层面,可将其纳入地役权法律制度范畴来调整和规制。但从长远层面来讲,应在深入挖掘地票交易之独特性的基础上,遵循其内在的特殊性面相,构建土地开发权交易法律规范体系来调整之,宜是较为理性的选择。

## 四、结　语

明晰土地产权、推动土地要素市场化和变

① 文兰娇、张安录《地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系》,《中国土地科学》2016 年第 7 期。

② 冯应斌、杨庆媛、慕卫东、刘燕《地票交易制度创新成效及其推广复制建议》,《经济体制改革》2016 年第 6 期。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

革政府土地管理体系,构成当下我国土地制度改革的主要内容。尽管前两项属于我国土地财产权结构改革的主要内容,而最后一项则属于我国土地管理权的内容,但须指出的是,明晰土地产权和推动土地要素市场化两大目标的实现离不开政府土地管理体系的改革。就此而言,改革我国现行土地管理权制度,不仅是突破这一权力运行困境的现实需要,而且亦是优化我国土地财产权结构的有力保障。

作为我国土地管理权重要组成部分的农用地开发许可权,在面向市场化价值取向改革过程中的路径选择无疑是前提性的议题。通过从法理层面对诸多试点方案的观察,可知我国农用地开发许可权市场化改革路径呈现出内在的变迁脉络,即初级形态的"土地换保障"模式、中级形态的建设用地"增减挂钩"模式到高级形态的"地票"交易模式。基于公平和效率价值之考量,当下的"地票"交易模式宜是我国农用地开发许可权市场化改革路径之最为理性的选择。故而现行法应认真对待这一新生事物。当然,将"地票"交易模式嵌入我国现行法体系中,亟须从法效应层面科学评估这一新生事物对我国现行的土地规划权、土地用途管制权、土地征收权等土地管理权的影响,并在立法上作出积极的回应。就此而论,本文的研究仅是开始,希冀能够引起学界对这一议题展开更为深入的研究。

## Market-oriented Reform of Agricultural Land Development Permission

ZHANG Xiangui

**Abstract:** Influenced by the traditional planned economy and path-dependent inertia, agricultural land development permission, in real law or in practice, is mainly realized through the single public law model of "command-comply", inattentive to the interests of various subjects, such as local governments, agricultural land-right holders, collective economic organizations. In practice, illegal land use is widespread for many subjects including local governments, that circumvent development permission of agricultural land, with the operation of this rights entering a dilemma to a certain extent. Market-oriented reform of agricultural land development permission is widely believed to be a possible solution to cater to the needs of diversified subjects. Based on the observation of many pilot land reform programs, it can be concluded that the market-oriented reform of agricultural land development permission in China is threefold, with the primary form of "land in exchange for social security", the intermediate form of "the increase and decrease equilibrium" of land for construction and the advanced form of "votes transactions". These three models have their pros and cons. Analyses were conducted on the constraints of existing institutional resources, the inherent changes, social effects, costs and benefits of these three models and other relevant factors. It is concluded that "votes transactions" is the optimal way to achieve market-oriented reform of agricultural land development permission in our country, or the option "with the least amount of defects". The current law should respond positively to it by corresponding law techniques, so as to let it "take root" in the real law.

**Keywords:** agricultural land development permission; market-oriented; land in exchange for social security; increase and decrease equilibrium; votes transactions

**ZHANG Xiangui**, postdoctoral candidate in law, East China University of Political Science and Law, Shanghai, 201620; associate professor & M. A. supervisor, Law School, Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306.

责任编校:徐玲英



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net